

刑法

No.71

H25-3

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、医師免許を有していなかったが、女性乙に対し、医学的に必要とされる措置をとることなく豊胸手術を行った。女性乙が豊胸手術に伴う身体傷害につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に傷害罪（刑法第204条）は成立しない。
- イ. 甲は、民事訴訟の証拠調べの期日において、証人として宣誓の上、虚偽の陳述をした。原告乙及び被告丙の双方とも甲が虚偽の陳述をすることにつきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に偽証罪（刑法第169条）は成立しない。
- ウ. 甲は、重病の母親乙の首をロープで絞めて殺害した。乙が殺害につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に殺人罪（刑法第199条）は成立しない。
- エ. 甲は、12歳の女兒乙の同意を得て、女兒乙に対してわいせつな行為を行った。甲に準強制わいせつ罪（刑法第178条第1項）は成立しない。（解答不能）
- オ. 甲は、交通違反の取締りを受けた際、警察官に対し、乙の氏名を名乗り、交通事件原票の供述書欄に乙名義で署名押印した。乙が名義使用につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に有印私文書偽造罪（刑法第159条第1項）は成立しない。

1. ア イ 2. イ ウ 3. ウ エ 4. エ オ 5. オ ア

No71	被害者の承諾	正答率
H25-3	正解	81%
	解答不能	

ア 誤っている

東京高判平9.8.4。本記述では乙が豊胸手術に伴う身体障害につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に傷害罪（204条）が成立するかが問題となる。裁判例は、本記述同様の事案において、被害者の「承諾があるとしても、もとより違法性を阻却しない」としている。その理由として、裁判例は、「被告人が被害者に対して行った医療行為は、身体に対する重大な損傷、さらには生命に対する危難を招来しかねない極めて無謀かつ危険な行為であって、社会通念上許容される範囲・程度を超えて、社会的相当性を欠く」としている。よって、甲には傷害罪が成立する。

イ 誤っている

本記述では、原告乙及び被告丙の双方とも甲が虚偽の陳述をすることにつきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、被害者の同意により違法性が阻却され、甲に対する偽証罪（169条）の成立が否定されるのではないかが問題となる。被害者の同意により行為の違法性が阻却される場合は、同意の内容が被害者にとって処分可能な個人法益に関するものである場合に限られる。偽証罪の保護法益は、国の審判作用の適正な運用という国家法益に関するものであって、被害者にとって処分可能な個人法益ではない。よって、訴訟の当事者が虚偽の陳述に同意していたとしても、偽証罪の成立に影響を及ぼさず、甲には偽証罪が成立する。

ウ 正しい

202条後段。人を承諾を得て殺した者には同意殺人罪が成立する。同意殺人罪は、殺人罪（199条）の特別罪であり、同意殺人罪が成立する場合、殺人罪の成立は排除される。乙が殺害につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合であるから、甲に同意殺人罪が成立し、殺人罪は成立しない。

エ 解答不能

本記述の当時の出題意図は、強制わいせつ罪が成立するのか準強制わいせつ罪が成立するのかを問うものであり、13歳未満の者に対する強制わいせつ罪は、被害者の同意があっても成立するということが理解できていれば、強制わいせつ罪が成立し、準強制わいせつ罪は成立しない—本記述は正しい—という帰結だった。それが令和5年の刑法改正により「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」という罪名は無くなり、両者とも「不同意わいせつ罪」として整理されたため、本記述は解答不能となった。なお、被害者の同意年齢についても13歳未満から16歳未満へと引き上げられた。

オ 誤っている

最決昭56.4.8（百選Ⅱ97事件）。あらかじめ作成名義人の承諾を得て、作成名義人以外の者が交通事件原票の供述書を作成する行為に、有印私文書偽造罪（159条1項）が成立するかについて、判例は、「あらかじめその他の人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立すると解すべきである」としている。理由として、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されない」ことを挙げている。よって、有印私文書偽造罪が成立する。